

TECNICATURA
UNIVERSITARIA EN
ADMINISTRACIÓN

LEGISLACIÓN I



TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN

UNIDAD 2

FUENTES DEL DERECHO

UNIDAD 2: FUENTES DEL DERECHO

PRESENTACIÓN

La presente unidad se encuentra orientada a la introducción del alumno en el análisis de las Fuentes del Derecho como medios de la creación del Derecho.

Dentro de las Fuentes del Derecho se analizará a la Ley en sentido amplio, como un elemento que comprende no sólo a la Ley propiamente dicha, sino también, a los Tratados Internacionales y a la Constitución Nacional.

Luego se analizará a la costumbre, a la jurisprudencia y a la Doctrina como Fuentes del Derecho.

Seguidamente, se estudiará la División de Poderes y la Supremacía Constitucional en la Constitución Nacional de la República Argentina. De estos temas, se deriva el análisis del Control de Constitucionalidad y la distinción entre normas operativas y programáticas.

Posteriormente, se entrará en el análisis del Sistema Federal de Gobierno, distinguiendo las competencias del Estado Federal, las provincias y los municipalidades.

Por último, se verán las nociones de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo y las diferencias entre sí.

OBJETIVOS

QUE LOS PARTICIPANTES:

- Aprendan las distintas Fuentes del Derecho.
- Entiendan el ámbito de aplicación y jerarquía de la Constitución Nacional y los Tratados internacionales, especialmente respecto de los referidos a los Derechos Humanos.

- Comprendan el sistema federal de Gobierno, y los distintos niveles de competencias del Estado Nacional, las Provincias y las Municipalidades.
- Incorporen los elementos esenciales para diferenciar el Derecho Constitucional del Derecho Administrativo.

TEMARIO

- 1. Fuentes del Derecho: Constitución Nacional. Ley. Tratados Internacionales. Costumbre. Jurisprudencia. Doctrina. Fuentes materiales y formales.**
- 2. La Constitución Nacional: División de Poderes. Estructura. Supremacía Constitucional. Control de Constitucionalidad. Normas operativas y programáticas.**
- 3. El Sistema Federal de Gobierno: competencias constitucionales del Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalidades.**
- 4. Noción de Derecho Constitucional y Administrativo. Alcances.**

1. Fuentes del Derecho: Constitución Nacional. Ley. Tratados Internacionales. Costumbre. Jurisprudencia. Doctrina. Fuentes materiales y formales.

Se denominan fuentes del Derecho a las instituciones jurídicas mediante las cuales se crean o manifiestan las normas y principios que integran el Derecho.

El concepto de Fuentes como origen de las normas positivas tiene varias acepciones a saber:

- 1) La “manifestación” o “constancia” de la norma, por la cual se conoce que en el orden jurídico existe una norma; en este sentido, la fuente parece ser la misma norma;
- 2) El “acto de creación” o de establecimiento de la norma;
- 3) El conjunto de ideas, valoraciones, normas y realidades, que sirven de inspiración para el contenido de la norma.¹



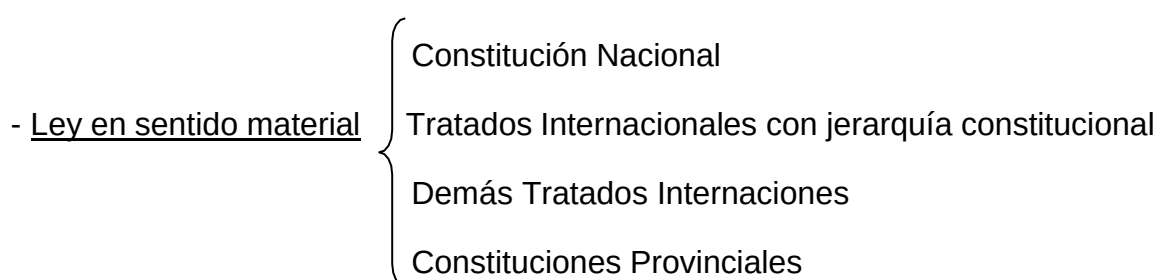
En los siguientes puntos se analizarán las **Fuentes del Derecho** “como aquellos hechos a los que se les reconoce, en un grupo o comunidad jurídica, la virtud de introducir (o sustraer) normas y, complementariamente, políticas, principios o valoraciones que son utilizados por los mismos miembros de la comunidad o por los órganos establecidos para ello (jueces y tribunales) a fin de determinar el sentido de las conductas de sus miembros y los comportamientos que deben observarse, inclusive en los casos de controversia”.²

¹ Cfr. BIDART CAMPOS, Germán; Manual de la Constitución reformada, Tomo I, Ed. Ediar, Bs. As., 1997, pág. 6.

² AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 571.

- **La ley como fuente del Derecho.**

El concepto de Ley como Fuente del Derecho incluye no sólo a la Ley en su aspecto formal (Leyes Nacionales y Provinciales), sino también a su sentido material, que comprende a la Constitución Nacional, a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (Art. 75, inc. 22 CN), a las Constituciones Provinciales, a los demás Tratados Internacionales.



- **Constitución Nacional.**

La Constitución Nacional de la República Argentina se sancionó en el año 1853, incorporándose la Provincia de Buenos Aires en 1860. En un sentido general, la constitución es el acto fundacional de organización política de una comunidad, definiendo las reglas de juego sobre las cuales se desarrollarán las relaciones del poder político y la convivencia social. De esta forma, la constitución es la unidad orgánica de la comunidad, fijando el mecanismo bajo el cual operará su funcionamiento.³

En la constitución son expuestos de manera orgánica los principios fundamentales del ordenamiento normativo de una organización política, incluyendo los valores institucionales y sociológicos de esa comunidad. La Constitución es un documento jurídico, pero además, es un instrumento de gobierno para concretar los grandes fines fijados por el constituyente.⁴

³ Cfr. BADENI, Gregorio; Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, 2° ed. actualizada, Ed. La Ley, Bs. As., 2006, pág. 60.

⁴ Cfr. BADENI, Gregorio; Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, 2° ed. actualizada, Ed. La Ley, Bs. As., 2006, pág. 13.

Los **caracteres** de nuestra Constitución Nacional:

- 1) La constitución es una ley.
- 2) Por ser ley suprema, se la considera como una super ley.
- 3) Esta ley suprema es escrita.
- 4) Reunida en un texto único y sistematizado.
- 5) Su origen se encuentra en la voluntad del pueblo mediante el poder Constituyente, mediante la Convención Constituyente.⁵

- **Tratados Internacionales.**

Conforme a la Constitución Nacional, el manejo de las relaciones exteriores corresponde conjuntamente al Poder Ejecutivo Nacional y al Honorable Congreso de la Nación. El primero es el encargado de negociar, concluir y firmar los tratados, concordatos y convenciones, y el segundo, tiene a su cargo su aprobación o rechazo. Es decir, que las relaciones internacionales son manejadas en forma conjunta por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación. No obstante, la aprobación o rechazo de los tratados internacionales es una facultad privativa del Poder Legislativo, formalizada mediante la sanción de una ley.



“Todos los tratados internacionales aprobados por el Congreso, cualquiera sea su contenido, tienen jerarquía superior a las leyes. Un tratado deroga, expresa o implícitamente, a toda ley y norma de inferior jerarquía que se oponga a sus contenidos. En cambio, una ley posterior no deroga a un tratado”.⁶

Por un lado, la facultad del Poder Ejecutivo surge del art. 99, inc. 11, de la Constitución Nacional en los siguientes términos: "Concluye y firma tratados, concordatos

⁵ Cfr. BIDART CAMPOS, Germán; Manual de la Constitución reformada, Tomo I, Ed. Ediar, Bs. As., 1997, pág. 4.

⁶ BADENI, Gregorio; Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, 2º ed. actualizada, Ed. La Ley, Bs. As., 2006, pág. 255.

y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras (...).

Por otro lado, la facultad del Poder Legislativo surge del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional: "Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. (...)".

Luego de la reforma constitucional de 1994, surge claro de la Constitución Nacional que todos los tratados y convenciones internacionales tienen jerarquía superior a las leyes, existiendo desde entonces cinco tipos de tratados internacionales:

1) Los tratados internacionales denominados "comunes", que regulan materias extrañas a la integración y a los derechos humanos.

2) Los tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados por el Congreso sin la mayoría especial exigida por el art. 75, inc. 22, C.N.

3) Los tratados internacionales de integración regulados en el art. 75, inc. 24, C.N. Estos tipos de tratados no pueden de ningún modo desconocer o reducir la amplitud de la tutela a los derechos humanos garantizada en otros tratados internacionales, pero si pueden ampliar dicha tutela.

4) Los tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados por el Poder Legislativo con las mayorías especiales establecidas en el art. 75, inc. 22, C.N.

5) Los tratados internacionales sobre derechos humanos enunciados expresamente en el art. 75, inc. 22, C.N.

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
- Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo.
- Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes.

Tratados Internacionales
con jerarquía
Constitucional
(art. 75, inc. 22 C.N.)

* Por Ley N° 24.820 se otorgo jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.

El carácter supralegal de los tratados internacionales únicamente cede ante las leyes internas que otorguen una protección más favorable a los derechos y garantías de las personas (conforme art. 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). En estos casos, la ley interna sólo suspende la aplicación de las cláusulas de los tratados internacionales, no los deroga ni modifica.



"La referencia a la jerarquía constitucional de los tratados sobre derechos humanos, significa que están incorporados operativamente al orden jurídico interno argentino y sujetos a las disposiciones contenidas en los arts. 27, 30 y 31 de la Ley Fundamental. No son supraconstitucionales ni forman parte de la Constitución. Si formaran parte de la Constitución, se estaría violando el art. 30 de ella porque, los enunciados en el art. 75, inc. 22, pueden ser denunciados sin intervención de una Convención Reformadora, y otro tanto los aprobados después de la reforma de 1994. Si no se acepta esta conclusión, tendríamos que admitir que fue reformado el art. 30 de la Ley Suprema, cuya modificación estaba prohibida por la ley 24.309 bajo la pena de nulidad".⁷

Los tratados internacionales sobre derechos humanos rigen en las condiciones de su vigencia, es decir, en conformidad con las reservas y declaraciones interpretativas efectuadas en el momento de su aprobación. No pueden derogar ni modificar artículo alguno de la Primera Parte de la Constitución, conforme art. 75, inc. 22, C.N.; y son complementarios de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. De esta

⁷ BADENI, Gregorio; Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, 2° ed. actualizada, Ed. La Ley, Bs. As., 2006, pág. 274 y 275.

forma, los tratados internacionales no crean derechos, garantías o libertades, sino que reglamenta -con jerarquía superior a las leyes- las ya reconocidas por la Constitución Nacional.⁸

- **Ley.**

Como ya vimos, la Ley puede verse desde dos puntos de vista: el **material** y el **formal**. Según el primero, también denominado **sustancial**, ley es toda regla social obligatoria, emanada de autoridad competente. De esta forma, son también leyes la Constitución Nacional y las Constituciones Provinciales, las ordenanzas municipales, etc.

En cambio, desde un punto de vista **formal**, se denomina únicamente ley a toda norma sancionada por el Poder Legislativo, de acuerdo a los procedimientos constitucionales.⁹



Entonces, desde el punto de vista formal, “La Ley es la norma general establecida mediante la palabra por el órgano competente (legislador)”.¹⁰

Del plexo normativo existente surge una relación fundamental entre las leyes y las garantías constitucionales, denominado **principio de legalidad**. Este principio implica que las obligaciones y prohibiciones a los ciudadanos necesita de una ley del Congreso que lo prescriba o determine. En este sentido, el último párrafo del artículo 19 de la

⁸ Cfr. BADENI, Gregorio; Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, 2° ed. actualizada, Ed. La Ley, Bs. As., 2006, pág. 275 y 276.

⁹ Cfr. BORDA, Guillermo A.; Tratado de Derecho Civil - Parte General, Tomo I, Ed. Abeledo Perrot, 1999, pág. 62 y 63.

¹⁰ AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 591.

Constitución Nacional señala que: **“Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”**.¹¹

- **Costumbre.**

La importancia de la Costumbre como Fuente del Derecho ha ido variando a través del tiempo. Antiguamente, en las sociedades poco evolucionadas era la principal fuente del Derecho, pero a medida de la evolución de la civilización se fue determinando con más precisión a través de normas, los derechos y las obligaciones de los hombres. Los defectos más destacados de la costumbre son la falta de precisión, de certeza y de unidad, y en la medida que la legislación positiva fue en aumento, paralelamente, el campo jurídico de la costumbre fue disminuyendo.¹²



“La costumbre consiste en la observancia constante y uniforme de un cierto comportamiento por los miembros de una comunidad social, con la convicción de que responde a una necesidad jurídica”.¹³ En otras palabras, “La costumbre consiste en una conducta generalizada, constante y uniforme que adoptan los miembros de una sociedad con el convencimiento de que ella responde a una necesidad u obligación que es jurídicamente exigible”.¹⁴

De las definiciones transcritas, surge que la costumbre posee un factor psicológico, denominado conciencia de obligatoriedad. Es decir, “[p]ara que una práctica común asuma el rol de una costumbre, además de ser generalizada, constante y uniforme, deberá ser considerada como necesaria o inevitable para el logro de un objetivo

¹¹ Cfr. BIDART CAMPOS, Germán; Compendio de Derecho Constitucional, Ed. Ediar, 1° reimpresión, Bs. As., 2003, pág. 70.

¹² Cfr. BORDA, Guillermo A.; Tratado de Derecho Civil - Parte General, Tomo I, Ed. Abeledo Perrot, 1999, pág. 77; y LLAMBÍAS, Jorge J.; Tratado de Derecho Civil - Parte General, Tomo I, 16° ed. actualizada por Patricio Raffo Benegas, Ed. Perrot, Bs. As., 1995, pág. 68.

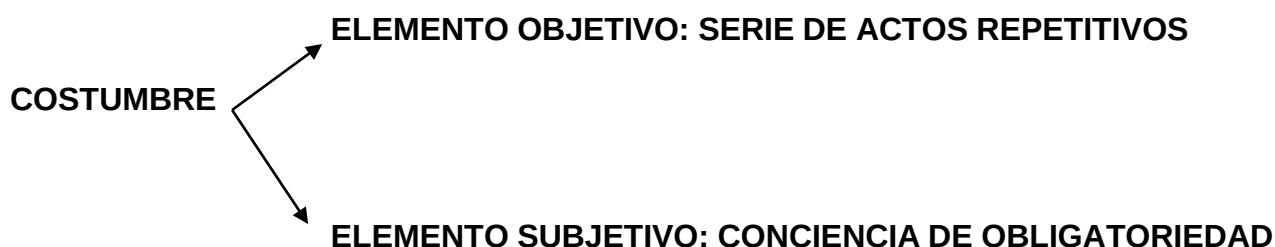
¹³ LLAMBÍAS, Jorge J.; Tratado de Derecho Civil - Parte General, Tomo I, 16° ed. actualizada por Patricio Raffo Benegas, Ed. Perrot, Bs. As., 1995, pág. 68 y 69.

¹⁴ BADENI, Gregorio; Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, 2° ed. actualizada, Ed. La Ley, Bs. As., 2006, pág. 15.

determinado. Debe responder al imperativo de satisfacer una necesidad que se traduzca en la imposición de la conducta con el carácter de una obligación jurídica.”¹⁵

Conforme a lo expuesto, la costumbre posee **dos elementos constitutivos**:

- 1) **Objetivo**: consistente en una serie de actos repetidos de manera constante y uniforme por la generalidad de las personas cuyas actividades están regidas por aquél;
- 2) **Subjetivo**: denominado psicológico, consistente en la convicción común de que la observancia de la práctica responde a una necesidad jurídica (este elemento diferencia a la costumbre de los simples usos sociales).¹⁶



“[E]l juzgador o intérprete reconoce a la costumbre como fuente cuando, para alcanzar la objetividad de su sentencia o conocimiento, muestra la conducta individual que le es sometida como un nuevo caso de ese núcleo ideal y genérico que se encuentra en esa repetición de conducta que es la costumbre. La costumbre es fuente toda vez que en ella encuentra el intérprete (o el juez) lo que necesita para afirmar la objetividad de su interpretación del caso: la existencia de un sentido genérico coincidente aceptado colectivamente por la comunidad.”¹⁷

¹⁵ BADENI, Gregorio; Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, 2° ed. actualizada, Ed. La Ley, Bs. As., 2006, pág. 16.

¹⁶ Cfr. BORDA, Guillermo A.; Tratado de Derecho Civil - Parte General, Tomo I, Ed. Abeledo Perrot, 1999, pág. 78; LLAMBÍAS, Jorge J.; Tratado de Derecho Civil - Parte General, Tomo I, 16° ed. actualizada por Patricio Raffo Benegas, Ed. Perrot, Bs. As., 1995, pág. 69; y AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 631; y BADENI, Gregorio; Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, 2° ed. actualizada, Ed. La Ley, Bs. As., 2006, pág. 16.

¹⁷ AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 624 y 625.

En Argentina, el Derecho positivo acogió el principio de que la costumbre es fuente de derecho ante el silencio de la ley a través de la reforma del Código Civil por la Ley N° 17.711. El nuevo artículo 17 del Código Civil expresa: “Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente”.

- **Jurisprudencia.**

La palabra jurisprudencia tiene dos acepciones, por un lado, significa ciencia o conocimiento del Derecho (así lo define el Diccionario de la Real Academia Española, y es el derivado del latín *iuris prudentia*); y por el otro, el significado más general y común de la palabra, se encuentra referido a la reiteración de fallos de los tribunales judiciales, que sirven de precedentes a futuros pronunciamientos.¹⁸ En un sentido similar a la segunda acepción, se lo define como “al sentido concordante de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales del Estado”.¹⁹

La jurisprudencia gira alrededor de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales del Estado, manifestándose como una repetición o forma habitual o uniforme de pronunciarse por parte del Tribunal de Justicia.



“Los principios asentados en un pronunciamiento judicial aislado no son suficientes .para constituir jurisprudencia hasta tanto sean receptados de manera uniforme por los tribunales para resolver casos análogos o similares”.²⁰

¹⁸ Cfr. BORDA, Guillermo A.; Tratado de Derecho Civil - Parte General, Tomo I, Ed. Abeledo Perrot, 1999, pág. 84.

¹⁹ AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 642.

²⁰ BADENI, Gregorio; Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, 2° ed. actualizada, Ed. La Ley, Bs. As., 2006, pág. 20.

De esta reiteración de fallos judiciales denota la influencia de unos fallos sobre otros (sobre todo de los fallos de los tribunales de mayor jerarquía) y la presencia de un conjunto de principios y doctrinas comunes que surgen de su contenido. Es decir, del conjunto de fallos precedentes surge una especie de norma o regla general vigente en los tribunales sobre un punto determinado, al que todo tribunal recurre cuando debe pronunciarse sobre dicho punto en un nuevo caso.²¹

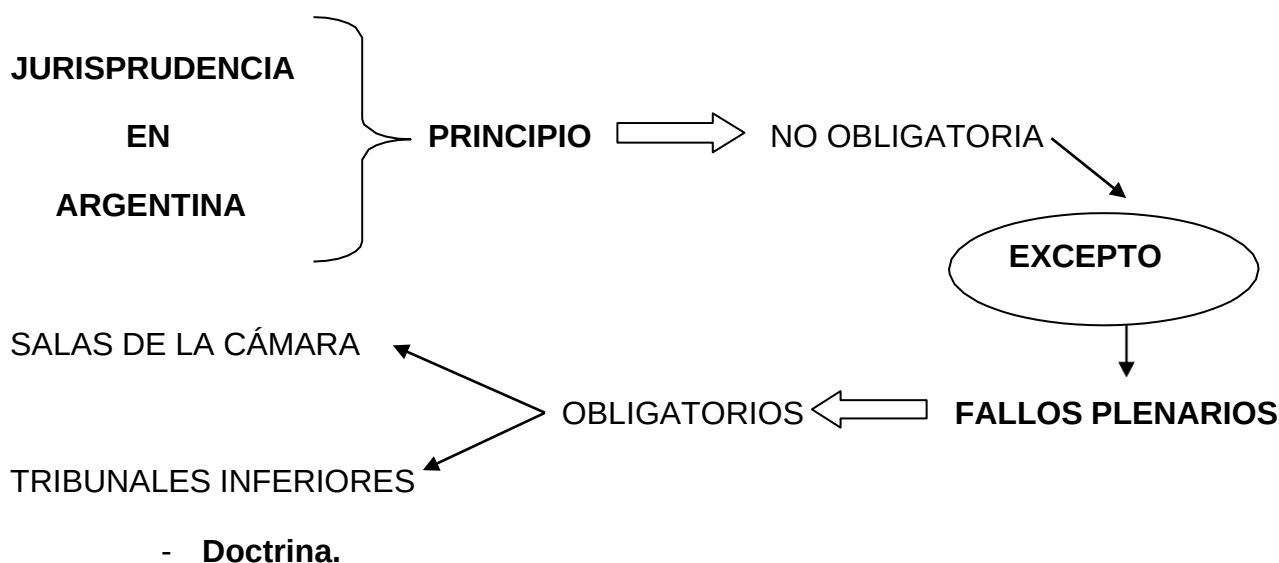
La jurisprudencia es Fuente del Derecho porque en definitiva son los tribunales de justicia quienes en un caso determinado, da el sentido último y final a la norma jurídica cuando la interpreta. En otras palabras, corresponde al Poder Judicial, y en última instancia, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la interpretación final de la Constitución Nacional y de las leyes. Según la interpretación que el tribunal establezca en un caso determinado, ese será el sentido de la norma jurídica para las partes, aunque estas sostengan otro sentido o interpretación.

En principio, la jurisprudencia no posee fuerza obligatoria para los jueces o demás miembros de la comunidad, aun cuando sea dispuesta por tribunales de mayor instancia o por la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, cuando existe antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema, los tribunales inferiores suelen ajustarse a sus fallos por razones de economía procesal y por el valor moral o simbólico de las sentencias del máximo tribunal del país.

Excepcionalmente, en determinadas circunstancias reguladas legalmente (art. 28 de la Ley N° 13.998) es obligatorio seguir la doctrina de los fallos de las Cámaras Nacionales de Apelación. Estos fallos son denominados fallos plenarios y son dictados por la Cámaras en Pleno, es decir, todas las salas de la Cámara se reúnen para dictar sentencia, siendo desde entonces obligatorio dicha jurisprudencia para las salas integrantes de la Cámara y para los jueces inferiores que dependen de ellas.²²

²¹ Cfr. AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 643.

²² Cfr. BORDA, Guillermo A.; Tratado de Derecho Civil - Parte General, Tomo I, Ed. Abeledo Perrot, 1999, pág. 88.



“La doctrina, como fuente indirecta del derecho, está compuesta por las opiniones formuladas por los juristas desde la cátedra universitaria, el libro y cualquier medio técnico de comunicación social, con el objeto de determinar el significado de las normas jurídicas existentes y de proyectar nuevas disposiciones legales destinadas a regular, con mayor eficacia, razonabilidad y justicia, las relaciones sociales.”²³

De todas las Fuentes del Derecho vistas hasta ahora, la doctrina es la que menor obligatoriedad tiene, ya que la única autoridad deriva de la fuerza de convicción de que está dotada. Es decir, los conceptos, teorías y posiciones jurídicas que realiza la doctrina nunca tienen entidad obligatoria para el juez o el legislador, quienes acuden voluntariamente a ellos para objetivar el sentido jurídico en un caso o legislar sobre una materia cuando lo estiman conveniente. Por ello, la doctrina tiene un carácter

²³ BADENI, Gregorio; Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, 2° ed. actualizada, Ed. La Ley, Bs. As., 2006, pág. 21 y 22.

exclusivamente voluntario, y su valor depende del prestigio y autoridad científica del jurista que la ha emitido.²⁴

En otras palabras, la doctrina carece de la obligatoriedad propia de la ley y la costumbre y en la que participa también, en cierta medida, la jurisprudencia. En estas fuentes, el sentido general obligatorio está directamente dado en la comunidad (costumbre) o en sus órganos (ley y jurisprudencia). En cambio, a la doctrina le falta este esté carácter obligatorio, directa o indirectamente.²⁵

Solo en el Derecho Romano se concedió -en determinado momento- a ciertos juristas de gran prestigio el *ius publice respondendi ex auctoritatis principiiis*, que consistía el poder de evacuar consultas, con fuerza obligatoria para el caso en particular y para los demás que luego se produzcan.²⁶

- Fuentes Formales y Materiales.

La teoría tradicional distingue las fuentes formales de las fuentes materiales del Derecho, señalando que las primeras son aquellas que en forma directa pasan a constituir el derecho aplicable, y las segundas, las que promueven u originan en sentido social-político a las primeras.²⁷

En otras palabras, las fuentes materiales son aquellas instituciones jurídicas que contribuyen a determinar el contenido concreto de las normas jurídicas. Las causas sociológicas que le dan un contenido concreto a las "fuentes materiales", para convertirse en Derecho aplicable vigente, deben transformarse en "fuentes formales". Es decir, para ser Derecho aplicable no alcanza que sean meras fuentes materiales, sino que deben adquirir la forma de las fuentes formales. En cambio, las Fuentes formales son aquellos hechos o actos a los cuales se les atribuye una específica aptitud para crear normas

²⁴ Cfr. AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 652.

²⁵ Cfr. AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 679.

²⁶ Cfr. BORDA, Guillermo A.; Tratado de Derecho Civil - Parte General, Tomo I, Ed. Abeledo Perrot, 1999, pág. 102.

²⁷ GORDILLO, Agustín; Tratado de derecho administrativo y obras selectas, Tomo 5 - Primeras obras, 1° ed, Fundación Derecho Administrativo, Bs. As., 2012, pág. IADA-V-1.

jurídicas. En este sentido, el procedimiento constitucional para la formación y sanción de las leyes determina que estas sean consideradas fuentes formales.²⁸

La doctrina no es totalmente uniforme respecto de cuales Fuentes del Derecho son formales y materiales.

Luego de esta aclaración, para la cátedra son:

1) **Fuentes Formales:** la **Ley en su concepción amplia** (Constitución Nacional, Tratados Internacionales y la Ley en sentido formal) y los Principios Generales del Derecho (analizados en la Unidad N° 1).

2) **Fuentes Materiales:** la **Costumbre**, la **Jurisprudencia** y la **Doctrina**.

2. La Constitución Nacional: División de Poderes. Estructura. Supremacía Constitucional. Control de Constitucionalidad. Declaraciones, Derechos y Garantías. Normas operativas y programáticas.

- La Constitución Nacional: División de Poderes

El poder como elemento integrante de Estado es un “poder político”, único e indivisible. Se manifiesta como la capacidad de determinar la conducta de los integrantes de la comunidad política organizada y tiene por finalidad la realización del bien común.²⁹

²⁸ Cfr. AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, pág. 561 y 562.

²⁹ Cfr. EKMEKDJIAN, Miguel Ángel; Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, 2° ed, Ed. Depalma, Bs. As., 2000, pág. 3; y BARRA, Rodolfo Carlos; Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Ed. Ábaco, Bs. As., 2002, pág. 270.



“El poder del Estado comprende, por una parte, el poder originario o constituyente, que reside en el pueblo o en la nación, y el poder derivado o poder de autoridad del que se encuentran investidos, en conjunto, los órganos o individuos para el cumplimiento de la actividad funcional del Estado”.³⁰

La Constitución Nacional no divide el poder, sino que lo distribuye y fragmenta en la cabeza de tres órganos independientes para que cumplan diferentes funciones. Así, el Poder Legislativo se encarga de la función de legislar, el Poder Judicial de la función de juzgar y el Poder Ejecutivo de la función de gobernar y administrar. Esta es la esencia de la división de poderes, que cada poder cumpla una función específica, y que su función, no pueda ser invadida por otro.



“Lo esencial de la división de poderes es la división de funciones [...] el que hace las leyes no sea el encargado de aplicarlas ni ejecutarlas; que el que las ejecute no pueda hacerlas ni juzgar su aplicación; que el que juzgue no las haga ni las ejecute”.³¹

La Corte Suprema desde sus comienzos resalto la división de poderes como un principio fundamental de la Constitución Nacional que se debía preservar. En este sentido sostuvo: “Siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división de gobierno en tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial,

³⁰ FAYT, Carlos; Derecho Político, Tomo I, 8º ed., Ed. Depalma, Bs. As., 1993, pág. 238.

³¹ GORDILLO, Agustín; Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, 6º ed., Ed. Fundación de Derecho Administrativo, Bs. As., 2003, pág. VIII-22.

independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno les son peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos y destruiría la base de nuestra forma de gobierno”.³²

Así, el fin de la división de poderes es que el poder contenga al poder, dividiéndolo y oponiendo sus partes para que se refrenen recíprocamente. De allí surge “sistema de frenos y contrapesos” o fractura del poder estatal. Se busca refrenar y limitar el poder estatal para que nadie pueda abusar de él, esta es la idea del sistema.³³ En pocas palabras, la división de poderes busca que los órganos estatales realicen un control recíproco entre sí, a fin de evitar el predominio de uno de ellos sobre los demás.

Por ello, si bien cada uno de los poderes tiene su propia esfera de acción, no están enteramente separados, porque se combinan y complementan entre sí, son coordinados. En este sentido, la Constitución Nacional establece numerosas e intensas relaciones entre los distintos poderes de gobierno, tanto de colaboración como de control, para el funcionamiento del Estado.³⁴

A partir de la interpretación de la división de poderes se determina el ámbito de actuación de los órganos públicos. El órgano encargado por la Constitución para realizar dicha interpretación y fijar los límites de cada poder es el Poder Judicial, por medio del control de constitucionalidad.

Puede observarse las diferentes interpretaciones del Principio de División de Poderes en los votos de la mayoría y de la minoría de la Corte Suprema en el caso “Cocchia”³⁵.

El voto de la mayoría sostuvo: “Nuestra Constitución establece un reparto de competencia a la vez que medios para su control y fiscalización, por los que se busca afianzar el sistema republicano. Atribuye a los distintos órganos facultades determinadas, necesarias para la efectividad de las funciones que se les asignan, y se asegura una relación de equilibrio, fijando órbitas de actividad y límites de autonomía, que al margen de su separación externa, no dejan de estar vinculadas por su natural interrelación funcional. Ahora bien, tal división no debe interpretarse en términos que equivalgan al

³² CSJN, “Ríos, Ramón y Otros”, *Fallos*, 1:32, cons. 2º.

³³ Cfr. GORDILLO, Agustín; *Tratado de Derecho Administrativo*, Tomo II, 6º ed., Ed. Fundación de Derecho Administrativo, Bs. As., 2003, pág. VIII-22.

³⁴ Cfr GONZALEZ, Joaquín V.; *Manual de la Constitución Argentina (1853-1860)*, actualizado por QUIROGA LAVIÉ, Humberto; La Ley, Bs. As., 2001, pág. 258; y SANTIAGO, Alfonso (h); *La Corte Suprema y el control político*, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., 1998, pág. *op. cit.*, pág. 77.

³⁵ CSJN, *Fallos*, 316:2624.

desmembramiento del Estado, en detrimento de un armonioso desenvolvimiento de los poderes nacionales”.³⁶

En cambio, la minoría expreso: “La misión más delicada de la justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar a las funciones que incumben a otros poderes, pero sin renunciar a la jerarquía que la Constitución – como su modelo norteamericano– reserva al acto de juzgar como acción propia del Poder Judicial, a cuya cabeza se halla este tribunal, con capacidad de control constitucional, como custodio de los valores básicos del sistema político jurídico. Tan celosa debe mostrarse esta Corte Suprema en el uso de sus facultades, cuanto en el respeto que la Ley Fundamental asigna a los otros poderes. El mantenimiento de ese delicado equilibrio es la más grande contribución que el Poder Judicial debe prestar a la seguridad jurídica y al bienestar general a fin de evitar que la concentración de competencias entre el Poder Ejecutivo de tipo presidencial y el Poder Legislativo conduzca a un abuso o desborde de poder que, bajo la aparente intención de una mayor eficacia en el logro del bienestar general rompa con el ordenamiento jurídico vigente, con prescindencia de la Constitución y la democracia”.³⁷

De los votos transcritos, surge que la mayoría del tribunal hace hincapié en que la División de Poderes no debe interpretarse de modo tal que equivalga a un desmembramiento del Estado, actuando cada uno por su lado, sino que debe interpretarse en sentido de posibilitar armonía en el desenvolvimiento de los poderes nacionales. En cambio, el voto de la minoría resalta que la División de Poderes no debe interpretarse de modo tal, que el Poder Judicial renuncie a la facultad de juzgar, ya que ello podría llevar a un abuso o desborde de poder por parte de los otros poderes.

- Estructura.

La Constitución Nacional de la República Argentina consta de un Preámbulo y 129 artículos. El Preámbulo es una enunciación previa donde se manifiestan los grandes motivos, principios, valores y fines que motivaron el dictado de la Constitución.

La Constitución Nacional se divide en dos grandes partes:

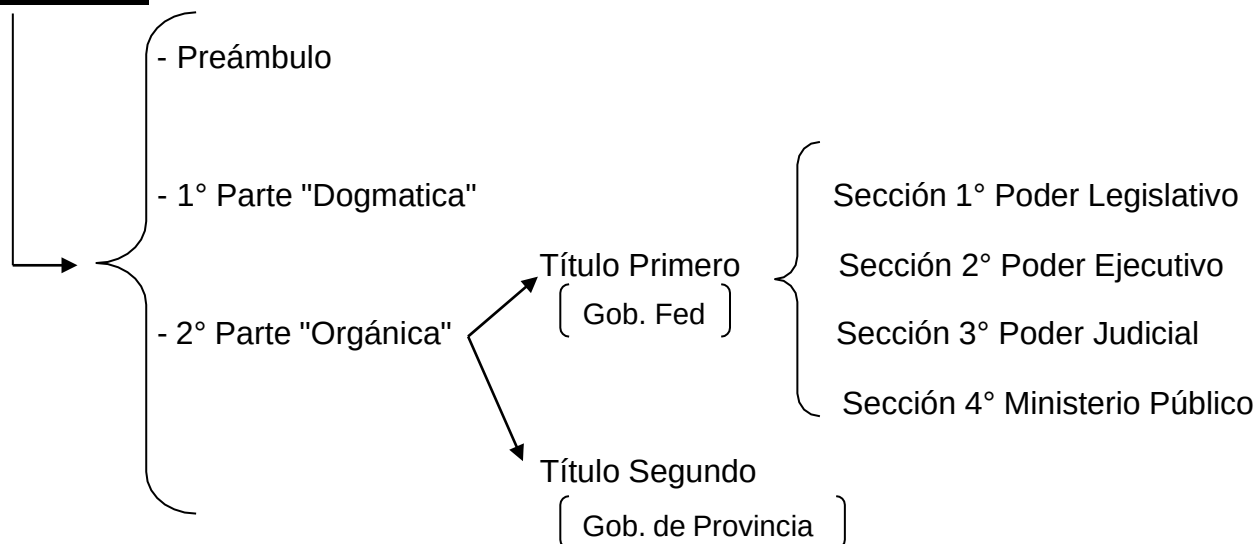
³⁶ Considerando 9° del Voto de los ministros Barra, Cavagna Martínez, Nazareno y Moliné O’ Connor.

³⁷ Considerando 15 del voto de los ministros Belluscio y Fayt.

1) Primera Parte: es la denominada "Parte Dogmática" o "Parte preceptiva", tiene 43 artículos, y aquí se establecen los Derechos y Garantías de los ciudadanos - declaración de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los particulares-, siendo un límite al accionar de los poderes públicos.

2) Segunda Parte: es la denominada "Parte Orgánica" de la Constitución, tiene 86 artículos, y aquí se regula la actuación de los tres Poderes del Estado -Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial-. Esta segunda parte se divide en dos Títulos, el primero referido al Gobierno Federal, que se subdivide en cuatro Secciones: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Ministerio Público. El segundo título regula todo lo referente a los Gobiernos de Provincia.

Estructura



- Supremacía Constitucional.

La Constitución es la organización político-jurídica fundamental de un Estado que establece principios, distribuye poder, declara derechos, atribuye competencias, determina funciones, y crea órganos.

La Constitución Nacional se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico, siendo su norma suprema. El resto de las normas que conforman el bloque de legalidad deben ser congruentes con ella, tanto en su forma como en su contenido, y las que así no

sean deben ser declaradas invalidas por los tribunales de justicia. Esto no es otra cosa, que el control de constitucionalidad que le corresponde al Poder Judicial.



"La esencia de nuestro sistema de gobierno radica en la limitación de los poderes de los distintos órganos y en la supremacía de la Constitución" (CSJN, *Fallos*, 254:43).

Aún antes de la reforma de 1994, se podía encontrar la preeminencia del derecho supranacional respecto de la leyes en el art 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, según el cual ninguna norma del derecho interno puede justificar que los estados signatarios de un tratado dejen de cumplir con las obligaciones contraídas al suscribir un acuerdo internacional. Sin embargo, fue recién en 1992 donde la Corte Suprema reconoció en el famoso caso "Ekmekdjian c/ Sofovich" la superioridad normativa de los tratados internacionales respecto de las leyes.³⁸

Luego, con la reforma del '94, se agrega el art. 75, inc. 22, C.N., que establece la superioridad jerárquica de los tratados internacionales y concordatos sobre las leyes, y se establecen diez tratados sobre derechos humanos que poseen jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia.

La superioridad del ordenamiento federal y su orden jerárquico se encuentra establecido en el art. 31 C.N.³⁹, en cuanto establece que la Constitución Nacional, las

³⁸ CSJN, *Fallos*, 315:1492 (07/07/1992). En el caso, la Corte sostuvo "Que la convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados [...] confiere primacía el derecho internacional convencional sobre el derecho interno". Por lo cual, "[...] la necesaria aplicación del art. 27 de la Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino asignar primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraría o con la omisión de dictar disposiciones que, en sus efectos, equivalgan al incumplimiento del tratado internacional [...]" (cons. 18º y 9º).

³⁹ Art. 31 CN: "Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto de 11 de noviembre de 1859".

leyes que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados internacionales son la ley suprema de la Nación. Este artículo, más el art. 43 y 116 de la Constitución Nacional⁴⁰, fundamentan la facultad de los jueces de imponer la supremacía constitucional mediante el control de constitucionalidad.

La Constitución Nacional encarga al Poder Judicial la función de garantizar su preeminencia sobre toda norma del orden jurídico. Es decir, el control de constitucionalidad, caso judicial de por medio, posibilita a los jueces verificar que todos los actos jurídicos -públicos y privados- se ajusten a las normas, principios y valores contenidos en la Constitución Nacional. De esta forma, las normas constitucionales precondicionan el actuar de los órganos estatales, estableciendo pautas y principios que deben ser respetados por estos.

Entonces, los tres planos de relaciones de supremacía que surgen del art. 31 C.N. son: 1) la supremacía de la Constitución respecto del resto del ordenamiento jurídico; 2) la supremacía de los tratados internacionales en relación a las leyes del Congreso, y 3) del ordenamiento federal respecto de los ordenamientos jurídicos locales (provinciales)⁴¹.

⁴⁰ Art. 43 CN: "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio".

Art. 116 CN: "Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inc. 12 del art. 75: y por los tratados con las naciones extranjeras: de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros: de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima: de los asuntos en que la Nación sea parte: de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero"

⁴¹ BIANCHI, Alberto; Control de Constitucionalidad, Tomo II, Ed. Ábaco, 2º ed., C.A.B.A., 2002, pág. 122.

- Control de Constitucionalidad.

El control de constitucionalidad consiste en la revisión acerca de la adecuación de las normas dictadas por las autoridades constituidas de un Estado con los requisitos establecidos en su Constitución Nacional.

Los sistemas de control de constitucional pueden circunscribirse tres modalidades⁴²:

- a) En el sistema jurídico británico (como en Holanda y en los países escandinavos) no hay un control judicial de constitucionalidad. Esto quiere decir que ningún juez interno -ni aún el máximo tribunal del país- puede descalificar una ley dictada por el Parlamento sobre la base de su contradicción a la Constitución (que en Gran Bretaña es consuetudinaria y no escrita). En estos ordenamientos jurídicos rige el principio de que el Parlamento es quien tiene la última palabra, aún en materia de derechos individuales.
- b) Los sistemas jurídicos de los países pertenecientes a la Europa continental poseen un control de constitucionalidad de tipo concentrado. Es decir, la capacidad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas está monopolizada por un solo órgano, el Consejo o Tribunal Constitucional.
- c) Por último, un tercer modelo de control de constitucionalidad es el norteamericano, y que es el adoptado por nuestra Constitución. Este sistema se caracteriza por ser difuso, es decir, puede ser ejercido por cualquier juez federal o local, a posteriori y en casos concretos.

En Argentina, la posibilidad del control de constitucionalidad está fundada en el artículo 31 C.N., que consagra el principio de supremacía constitucional; y en el artículo 116 C.N., que determina la competencia de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación para entender en todas las causas sobre puntos regidos por la Constitución Nacional.

⁴² NINO, Carlos; Fundamentos de Derecho Constitucional, Ed. Astrea, Bs. As., 1992, pág. 659.

Las principales **características** del control de constitucionalidad en la Argentina son:

1. Debe desarrollarse dentro de un **caso o controversia judicial**, lo que excluye el control genérico o abstracto, y la acción popular.
2. Es **difuso**, pues cualquier tribunal judicial puede ejercerlo. Es decir que se encuentra desconcentrado en diversos órganos del Poder Judicial, que no está monopolizado por un sector de la judicatura, aunque la Corte Suprema es la última y definitiva instancia de revisión extraordinaria.
3. **No procede**: en casos abstractos, ni en forma preventiva o consultiva.
4. La **declaración de la inconstitucionalidad de una norma** sólo puede darse en el curso de un procedimiento litigioso, es decir, en una controversia entre partes con intereses jurídicos contrapuestos, en la cual las formulaciones de inconstitucionalidad persigan la determinación de derechos debatidos entre las partes del juicio.
5. El efecto de la declaración de inconstitucionalidad es **inter partes**. Es decir, tiene efectos individuales y no generales o abstractos respecto a otros potenciales sujetos afectados por la norma cuestionada (aunque en algunos casos excepcionales, como en el fallo "Halabi" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación los efectos pueden ser *erga omnes*).
6. La declaración de inconstitucionalidad de una norma **carece de efectos derogatorios genéricos**. La ley declarada inconstitucional sigue vigente, pero no se aplica al caso concreto.

El control de constitucionalidad de oficio se refiere a que en el marco de una controversia judicial, el juez de la causa puede, aún sin pedido de parte, declarar la inconstitucionalidad de una norma jurídica en el caso.



“[El] control constitucional consagra el principio de que no toda ley o decisión estatal es derecho, otorgando al juez la facultad de no aplicar la norma injusta, irrazonable o incorrectamente sancionada”.⁴³

El fortalecimiento del control de constitucionalidad de oficio -desde la tesis que lo rechazaba, establecida en 1941 por la Corte en el fallo "Ganadera Los Lagos S.A."- operó como consecuencia de la ampliación del control con petición de parte luego del regreso de nuestro país al sistema democrático y, más tarde, al consagrarse en el orden interno, la jerarquía constitucional de los Tratados de Derechos Humanos, el control de convencionalidad y la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acerca de que éste debía ejercerse también de oficio.⁴⁴

En el caso "Mill de Pereyra" la Corte declara por primera vez la procedencia del Control de Constitucionalidad de Oficio, y lo volvió a ratificar, en "Banco Comercial de Finanzas". Posteriormente, en autos "Rodríguez Pereyra", el máximo tribunal sostiene que el Poder Judicial no sólo debe ejercer un control de constitucionalidad “de oficio”, sino también una especie de “control de convencionalidad de oficio”, entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos y las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- Normas operativas y programáticas.

En nuestra Constitución Nacional existen dos tipos de normas: las normas operativas y las programáticas.

⁴³ SANTIAGO, Alfonso (h); La Corte Suprema y el control político, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., 1998, pág. 126.

⁴⁴ GELLI, María; “La declaración de inconstitucionalidad de oficio. Fundamentos y alcances (en el caso Rodríguez Pereyra)”, La Ley 2013-A , pág. 25.

1).- Las Normas Operativas:

Son aquellas cláusulas constitucionales que no necesitan ser reglamentadas por las leyes para su aplicación en un caso concreto, debido a la autosuficiencia de la norma constitucional. Se pueden citar como ejemplos el debido proceso adjetivo (art. 18 C.N.), la abolición de la esclavitud (art. 15 C.N.), y el derecho de huelga (art. 14 bis C.N.), entre otros derechos.

2).- Las Normas Programáticas:

Son aquellas cláusulas constitucionales que necesitan ser reglamentadas por las leyes del Congreso para su aplicación a un caso concreto, debido a que la norma constitucional no es autosuficiente. Se pueden citar como ejemplo Ejemplos: la jornada laboral limitada de los trabajadores (art. 14 bis C.N.), el juicio por jurados (art. 24 CN), y todos los derechos sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Nacional.

3. El Sistema Federal de Gobierno: competencias constitucionales del Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalidades.

La Constitución Nacional establece que la República Argentina es un Estado Federal, siendo la nota distintiva de toda federación: la distribución o reparto de competencia entre los distintos Estados integrantes de la República y el Gobierno Central.

Nuestra Constitución estableció las competencias nacionales o federales delegadas expresamente, conservando para sí las provincias todo el poder no delegado. De allí, las provincias dictan sus propias constituciones provinciales y crean sus propias instituciones, disponiéndose tal facultad expresamente en el art. 5° C.N.: "Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones".



Este principio de conservación del poder no delegado a favor de las provincias se encuentra garantizado en el art. 121, C.N., en los siguientes términos: "Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación".

De esta forma, a partir de la sanción de la Constitución Nacional por la Convención Constituyente, las provincias conservan todos los poderes existentes con anterioridad y con la misma extensión, excepto que exista en la Carta Magna alguna cláusula que restrinja o prohíba tal facultad.

Así, los poderes de las provincias se encuentran limitados cuando⁴⁵:

- 1).- La constitución concede al Gobierno federal un poder exclusivo en términos expresos;
- 2).- Cuando el ejercicio de idénticos poderes ha sido prohibido a las provincias;
- 3).- Cuando hay incompatibilidad absoluta y directa en el ejercicio de los mismos por parte de las provincias.

Las competencias constitucionales el Gobierno Federal y las provincias se rigen por relaciones de subordinación, de participación y de coordinación⁴⁶:

⁴⁵ Cfr. JIMENEZ, Eduardo; Derecho Constitucional Argentino, Tomo I, Ed. EDIAR, 2001, pág. IX-15, disponible en <http://www.profesorjimenez.com.ar/publicaciones.htm> (24/05/2014).

⁴⁶ Cfr. JIMENEZ, Eduardo; Derecho Constitucional Argentino, Tomo I, Ed. EDIAR, 2001, pág. IX-16, disponible en <http://www.profesorjimenez.com.ar/publicaciones.htm> (24/05/2014).

- 1).- La relación de subordinación: esta relación actúa bajo la regla constitucional de la supremacía federal, implicando que los ordenes jurídicos provinciales deben subordinarse al orden jurídico federal.
- 2).- La relación de participación: afianza la cohesión del sistema, reconociendo la intervención de las provincias en la toma de decisiones del gobierno federal. Ejemplo: la integración por representantes de las provincias la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Nación.
- 3).- La relación de coordinación: delimita las competencias propias entre los órdenes jurídicos de las provincias y del gobierno federal.

Asimismo, el gobierno federal debe garantizar a cada provincia el goce y el ejercicio de sus instituciones -conforme art. 5° C.N.- cuando:

- 1).- La constitución provincial se dicte bajo el sistema representativo y republicano;
- 2).- El dictado de la constitución provincial sea acorde a los principios, declaraciones y garantías de la constitución federal;
- 3).- Asegure la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria.

Ejemplos de las distintas relaciones de competencia entre el gobierno federal y las provincias pueden observarse en el siguiente cuadro⁴⁷:

⁴⁷ Cfr. JIMENEZ, Eduardo; Derecho Constitucional Argentino, Tomo I, Ed. EDIAR, 2001, pág. IX-16, disponible en <http://www.profesorjimenez.com.ar/publicaciones.htm> (24/05/2014).

<u>TIPO DE RELACION COMPETENCIAL</u>	<u>EJEMPLOS EN LA CONSTITUCION TEXTUAL</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
Competencias exclusivas del gobierno federal	• Intervención Federal • Estado de sitio • Relaciones internacionales	Por lo genera, las competencias asignadas al gobierno federal, son exclusivas de la federación (aún así pueden haber competencias exclusivas implícitas del gobierno federal, como es el caso del art. 75 inc.32 de la C.N.
Competencias exclusivas de las provincias	• Dictar la constitución provincial • Dictar sus leyes procesales. • Crear regiones para el desarrollo económico y social	Es importante acotar aquí la reserva del art. 121 C.N.
Competencias concurrentes (gobierno federal y gobiernos provinciales)	• Crear impuestos indirectos internos • Dictado en conjunto con el gobierno federal, de las leyes de bases a que se refieren los arts. 41 y 75 inc. 17 C.N.	Los dos ámbitos (el provincial y el federal) poseen la misma habilitación para ejercerlas
Competencias compartidas por el estado federal y las provincias	• Fijación de la Capital Federal. • Creación de nuevas provincias •	Ellas reclaman para su ejercicio, una doble decisión integratoria (del estado federal y de cada provincia participante)
Competencias prohibidas a las provincias	• Casos de los arts.126 y 127 C.N.	En líneas básicas, coinciden con las competencias exclusivas del gobierno federal
Competencias excepcionales del estado federal	• Establecer impuestos directos por parte del Congreso, cuando la defensa, seguridad común y el bien general lo exigen, y por tiempo determinado (art. 75 inc. 2 C.N.)	Históricamente, una vez ejercidas han tendido a tornarse en permanentes, lo que implica una grave violación al sistema constitucional, al haber consentido el Poder Moderador estas circunstancias
Competencias excepcionales de las provincias	• Dictar los códigos de fondo y de derecho común, hasta que ellos sean dictados por el Congreso Nacional • Armar buques de guerra o levantar ejércitos en el caso y con los recaudos dispuestos en el art. 126 C.N.	Realmente, asumen su carácter de excepción.

Por su parte, la reforma constitucional de 1994 consagra en el art 123 C.N., la autonomía de las municipalidades y establece directivas institucionales a ser adoptadas por las provincias en sus constituciones. De esta forma, las provincias tienen el deber de asegurar la autonomía municipal, debiendo reglar el alcance y contenido en la esfera institucional, política, administrativa, económica y financiera.



Artículo 123 C.N.: "Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero".

De este modo, las provincias argentinas están constitucionalmente obligadas a adecuar sus constituciones en el sentido establecido por el art. 123 de la Constitución Nacional. Es decir, la Constitución Nacional declara la autonomía de las municipalidades y delega en cada provincia la reglamentación de su alcance y contenido.

Por último, queda analizar si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el estatus jurídico de una provincia o de una municipalidad. En esta cuestión, la doctrina constitucional se encuentra dividida: para un sector tiene el estatus de una provincia; para otro, de una municipalidad; y para una última postura, se manifiesta su carácter mixto.

Sin entrar en la discusión de fondo, la postura de la cátedra es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no alcanza la categoría de provincia, pero posee un régimen autonómico intermedio, otorgado y garantizado directamente por la Constitución.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación expresamente le negó el carácter de estatus provincial en autos "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c. Provincia de Tierra del Fuego"⁴⁸ de fecha 18 de diciembre de 2007.

4. Noción de Derecho Constitucional y Administrativo. Alcances.

⁴⁸ La Ley 15/02/2008, pág. 7.



"El Derecho Constitucional, resulta ser la rama del derecho público que se ocupa del estudio del Sistema Constitucional, integrado por las normas jusfundamentales que se refieren a la estructura del Estado, a la organización y la competencia de los poderes de gobierno y a los derechos, garantías y obligaciones individuales y colectivos, así como las instituciones que los garantizan, como asimismo la jurisprudencia, doctrina, práctica, usos y costumbres que asientan su aplicabilidad".⁴⁹

El derecho constitucional es el sector del mundo jurídico dedicado a la organización fundamental del Estado. El contenido de lo "fundamental" comprende la regulación de la estructuración de los poderes básicos del Estado y la delimitación de las facultades, competencias y atribuciones de los distintos poderes que lo componen, como así también, el reconocimiento de los derechos individuales y sociales esenciales.⁵⁰



En cambio, el Derecho Administrativo es "(...) el conjunto de normas y de principios de derecho público interno que tiene por objeto la organización y el funcionamiento de la administración pública, como así la regulación de las relaciones interorgánicas, interadministrativas y las de las entidades administrativas con los administrados".⁵¹

⁴⁹ JIMENEZ, Eduardo; Derecho Constitucional Argentino, Tomo I, Ed. EDIAR, 2001, pág. I-3, disponible en <http://www.profesorjimenez.com.ar/publicaciones.htm> (24/05/2014).

⁵⁰ Cfr. SAGÜÉS, Pedro; Manual de Derecho Constitucional, Ed. Astrea, C.A.B.A., 2007, pág. 19.

⁵¹ MARIENHOFF, Miguel; Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, 5° ed. Actualizada, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003, pág. 160.

Ambas ramas del derecho coinciden en pertenecer al sector del Derecho Público del Estado, pero mientras que el Derecho Constitucional se dedica a la regulación de los aspectos organizacionales esenciales de la comunidad política, el Derecho Administrativo se dedica a regular aspectos infra-constitucionales, es decir, regula en forma directa la conducta de la Administración Pública con los particulares.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

OBLIGATORIA

El material de estudio.

COMPLEMENTARIA

- AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José Manuel; y RAFFO, Julio; Introducción al Derecho; 3° edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999.
- BADENI, Gregorio; Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, 2° ed. actualizada, Ed. La Ley, Bs. As., 2006.
- BARRA, Rodolfo Carlos; Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Ed. Ábaco, Bs. As., 2002.
- BIANCHI, Alberto; Control de Constitucionalidad, Tomo II, Ed. Ábaco, 2° ed., C.A.B.A., 2002.
- BIDART CAMPOS, Germán; Compendio de Derecho Constitucional, Ed. Ediar, 1° reimpresión, Bs. As., 2003.
- BIDART CAMPOS, Germán; Manual de la Constitución reformada, Tomo I, Ed. Ediar, Bs. As., 1997.
- BORDA, Guillermo A.; Tratado de Derecho Civil - Parte General, Tomo I, Ed. Abeledo Perrot, 1999.
- EKMEKDJIAN, Miguel Ángel; Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, 2° ed, Ed. Depalma, Bs. As., 2000.
- FAYT, Carlos; Derecho Político, Tomo I, 8° ed., Ed. Depalma, Bs. As., 1993.
- GELLI, María; "La declaración de inconstitucionalidad de oficio. Fundamentos y alcances (en el caso Rodríguez Pereyra)", La Ley 2013-A.

- GONZALEZ, Joaquín V.; Manual de la Constitución Argentina (1853-1860), actualizado por QUIROGA LAVIÉ, Humberto; La Ley, Bs. As., 2001.
- GORDILLO, Agustín; Tratado de derecho administrativo y obras selectas, Tomo 5 - Primeras obras, 1º ed, Fundación Derecho Administrativo, Bs. As., 2012.
- GORDILLO, Agustín; Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, 6º ed., Ed. Fundación de Derecho Administrativo, Bs. As., 2003.
- JIMENEZ, Eduardo; Derecho Constitucional Argentino, Tomo I, Ed. EDIAR, 2001, disponible en <http://www.profesorjimenez.com.ar/publicaciones.htm> (24/05/2014).
- LLAMBÍAS, Jorge J.; Tratado de Derecho Civil - Parte General, Tomo I, 16º ed. actualizada por Patricio Raffo Benegas, Ed. Perrot, Bs. As., 1995.
- MARIENHOFF, Miguel; Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, 5º ed. Actualizada, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003.
- NINO, Carlos; Fundamentos de Derecho Constitucional, Ed. Astrea, Bs. As., 1992.
- SAGÜÉS, Pedro; Manual de Derecho Constitucional, Ed. Astrea, C.A.B.A., 2007.
- SANTIAGO, Alfonso (h); La Corte Suprema y el control político, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., 1998.